

1502262-21.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 26/09/2022

... da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502262-21.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502262-21.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HELIO HERNANI DOS SANTOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

HELIO HERNANI DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, c.c. o artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 e no artigo 16, caput e §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 25 de junho de 2022, na madrugada, na Rua José Bonifácio, na altura do número 448, nesta cidade, agindo previamente acordado e com unidade de desígnios com o adolescente P.E.B.M., mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, a motocicleta Honda CG 125, de placas FID7418, de propriedade de J.M.O.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas no parágrafo anterior, o acusado facilitou a corrupção de pessoa menor de dezoito anos de idade, com ela praticando infração penal.

Consta, por fim, que, no dia 28 de junho de 2022, à tarde, na Avenida Capitão Luiz Antônio Pimenta, na altura do nº 563, nesta cidade, o acusado possuía e portava

arma de fogo, sendo um revólver Taurus, calibre 38, com numeração raspada e suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia, o réu foi citado e ofereceu resposta à acusação. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma das testemunhas arroladas na denúncia. Foi homologada a desistência das partes quanto à oitiva de uma testemunha policial militar. Ao final, foi o réu interrogado. Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do réu nos termos da denúncia, diante da prova produzida. Pediu a fixação da pena-base em seu mínimo legal e o reconhecimento da circunstância agravante relativa à calamidade pública quanto aos três crimes, com a incidência da circunstância atenuante da confissão somente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Pugnou pelo reconhecimento das majorantes do crime de roubo, descritas na denúncia, e, ao final, pediu a fixação do regime inicial fechado. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado pelos crimes de roubo e de corrupção de menores, por falta de prova quanto à autoria relativa àquele e por falta de provas quanto à efetiva corrupção do menor quanto a este. Requereu, também a absolvição do réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, com a aplicação do princípio da consunção. Subsidiariamente, pugnou pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, pelo afastamento da circunstância agravante relativa à calamidade pública, e pelo afastamento da incidência cumulativa das frações de aumento referentes às duas majorantes do crime de roubo.

É o relatório.

DECIDO.

A prova da materialidade dos crimes emerge do auto de prisão em flagrante, dos boletins de ocorrência de fls. 22/24 e de fls. 26/28, do auto de exibição e apreensão, do auto de entrega, do laudo pericial da arma de fogo, bem como da prova oral colhida em Juízo e demais elementos constantes nos autos.

A autoria dos delitos é indubitável.

Interrogado em Juízo, o acusado admitiu que estava portando a arma de fogo e negou a prática dos crimes de roubo e de corrupção de menor descritos na denúncia. Alegou que não participou do roubo da motocicleta e que foi abordado com o adolescente no veículo, cuja procedência ilícita desconhecia, porque havia pedido carona a ele para ir ao centro da cidade. Disse que não sabia o nome do adolescente, pois somente o conhecia de vista da rua, e também não sabia para onde o adolescente iria. Contou que havia encontrado o armamento alguns dias antes e estava com ele em sua posse, pois o revenderia no centro da cidade. Não soube por que motivo foi reconhecido como um dos autores do crime de roubo. Disse que trabalhava com reciclagem.

Entretanto, a negativa do acusado quanto à prática dos crimes de roubo e de corrupção de menor e a versão por ele apresentada estão isoladas no conjunto probatório amealhado.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou ter sido roubada e descreveu como se deu a ação criminosa e a conduta do acusado. Declarou que, na madrugada da data dos fatos, retornava para sua casa em sua motocicleta e, ao reduzir a velocidade em um semáforo vermelho, viu, pelo retrovisor, outra motocicleta aproximando-se rapidamente. Disse que naquela motocicleta havia dois indivíduos e, quando o condutor parou a motocicleta ao seu lado, o réu, que estava na garupa, retirou um revólver da cintura, apontou-o para sua cabeça e a ameaçou, mandando que entregasse sua motocicleta ou morreria no local. Relatou que desembarcou de seu veículo e o entregou aos meliantes, sendo que o acusado apoderou-se dele, evadindo-se atrás do comparsa que permaneceu na motocicleta que conduzia. Declarou que, em cerca de três dias, recebeu a informação da polícia de que sua motocicleta havia sido recuperada. Soube pelos policiais que eles avistaram dois indivíduos com seu veículo e que os abordaram em razão de suas condutas, apreendendo, também, a arma de fogo que havia sido usada durante o roubo. Narrou que foi à delegacia, onde reconheceu, sem dúvidas, o acusado e seu comparsa, dentre outros dois indivíduos, como os autores do crime. Consignou que os meliantes usavam capacetes abertos durante a ação criminosa e olhou fixamente o rosto de ambos, podendo, por isso, identificá-los. Relatou que ambos eram pessoas jovens, sendo que

o réu tinha pele de cor morena clara, corpo magro e trajava casaco. Afirmou que também reconheceu o armamento apreendido pelos policiais como sendo aquele usado durante o roubo, pois o olhou e viu que se tratava de um revólver, que estava muito velho, de calibre 38, cujas características conhece por fotografias. Reconheceu o réu em Juízo, sem dúvidas, como sendo um dos autores do crime.

A testemunha policial militar Bruno do Nascimento José, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que, durante patrulhamento de rotina, viu dois indivíduos em uma motocicleta e observou que aquele que estava na garupa, ao ver a equipe policial, levou a mão à cintura como se estivesse segurando algo, o que motivou a abordagem. Narrou que, feita a busca pessoal, na cintura do réu, que estava na garupa da motocicleta, encontrou uma arma de fogo municiada e com numeração suprimida. Declarou que o indivíduo que pilotava a motocicleta era um adolescente e, questionado sobre a procedência da motocicleta, ele informou ser produto de roubo cometido em data anterior. Relatou que o acusado nada informou sobre a procedência do armamento. Disse que o réu e o adolescente foram conduzidos à delegacia, onde a vítima os reconheceu como sendo os autores do roubo de sua motocicleta, ocorrido em data anterior.

Em face de toda a prova carreada aos autos, diante das declarações da vítima e do depoimento da testemunha policial em Juízo, os quais foram fornecidos com segurança e detalhes, não há dúvidas em se concluir que o réu efetivamente participou do delito de roubo e também praticou os crimes de corrupção de menor e de porte ilegal de arma de fogo descritos na denúncia.

As declarações da vítima e o depoimento da testemunha policial complementam-se e são coerentes e harmônicos entre si, estando seus relatos em verdadeira consonância com aqueles apresentados na fase extrajudicial.

Assim, em relação ao depoimento da vítima em casos como o dos presentes autos, destacam-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubo ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si” (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250)

“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos” (TACRIM-SP-AC-Rel. Celso Limongi-JUTACRIM 94/341).

Quanto ao testemunho do agente policial, com enorme grau de confiabilidade, também presta-se a viabilizar a condenação do acusado.

Em relação ao valor probatório do depoimento de testemunha policial destaca-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais

testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1a Turma - HC n. 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

Ao contrário do alegado pela Defesa, não há quaisquer dúvidas quanto ao reconhecimento do acusado pela vítima.

Ressalte-se que a vítima afirmou ter realizado o reconhecimento do réu e do adolescente quando esteve na delegacia, após a comunicação feita por policiais sobre a localização de sua motocicleta, asseverando que os viu entre outros indivíduos e pode, sem dúvidas, identificá-los como autores do crime, o que também se depreende do auto de reconhecimento de fls. 19.

Consignou a vítima que, embora não tivesse o réu nenhuma característica peculiar que se destacasse, ele e o adolescente usavam capacetes que deixavam seus rostos à mostra no momento da ação criminosa, e afirmou que olhou fixamente seus rostos naquela ocasião.

Veja-se que a vítima pode detalhar a conduta praticada pelo réu durante a execução do crime de roubo, esclarecendo que foi ele o indivíduo que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo comparsa e que foi o acusado quem empunhou a arma, apontando-a em sua direção e que se evadiu do local dos fatos na posse de seu veículo, seguindo o comparsa que permaneceu na outra motocicleta usada na ação criminosa.

Por fim, ao visualizar o acusado dentre outros dois indivíduos no ato de reconhecimento judicial, a vítima apontou o réu como sendo o indivíduo que participou do crime de roubo, demonstrando plena certeza quanto à sua identificação.

Frise-se que deve ser dada normal credibilidade às declarações apresentada pela vítima, uma vez que não restou demonstrado nos autos ter ela intenção de prejudicar o réu.

Seu relato foi firme e inequívoco, não havendo razões para se duvidar do que foi dito por ela, nem mesmo do reconhecimento por ela realizado.

Já a testemunha policial, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou ter abordado o acusado juntamente com o adolescente quando os viu em uma motocicleta pilotada por este último e após ter observado que o réu havia colocado a mão na cintura. Relatou que, com o réu, apreendeu um revólver municiado e sem número de identificação e soube, pelo adolescente, que a motocicleta era produto de roubo ocorrido anteriormente.

Acrescentou, ainda, que o réu e seu comparsa adolescente foram conduzidos à delegacia, onde a vítima os reconheceu como sendo os autores do crime de roubo de sua motocicleta.

Portanto, não restam dúvidas sobre a autoria do crime de roubo, cometido mediante concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo.

O crime se consumou, uma vez que o acusado e seu comparsa adolescente conseguiram apoderar-se do bem da vítima, invertendo sua posse. Outrossim, a motocicleta somente foi localizada durante abordagem policial ocorrida três dias após o roubo. Finalmente, as causas de aumento de pena do crime de roubo restaram demonstradas pela prova amealhada aos autos.

A vítima bem esclareceu que o acusado praticou o crime juntamente com seu comparsa adolescentes, dividindo as tarefas no momento do crime, de maneira a executá-lo de forma mais eficiente.

Saliente-se que o concurso está configurado ainda que o crime tenha sido praticado em concurso apenas com menor de dezoito anos, uma vez que é irrelevante que um dos agentes seja inimputável. Nesse sentido, destaca-se o seguinte posicionamento jurisprudencial:

TACRSP "A simples presença de duas pessoas em um assalto é suficiente para intimidar a vítima, convertendo-se em roubo a ação furtiva. É ainda pacífico o entendimento de que o concurso de duas pessoas qualifica o roubo, ainda que um deles seja menor inimputável" (RT 694/345).

Da mesma forma, a vítima ressaltou a utilização de arma de fogo durante a ação criminosa. Asseverou que a arma de fogo lhe foi exibida pelo acusado e acrescentou

que, ao comparecer à delegacia, também realizou o reconhecimento da arma de fogo apreendida pelos policiais como sendo o armamento utilizado para a execução do roubo, esclarecendo que se tratava de um revólver que aparentava ser antigo. Saliente-se que a ausência de apreensão da arma usada no crime não afasta a majorante. Nesse sentido, destaca-se o entendimento do extinto Tribunal de Alçada Criminal – TACrimSP:

“ROUBO QUALIFICADO - Ausência de apreensão da arma - Irrelevância. O fato de não ser apreendida a arma usada no crime de roubo não afasta a qualificadora, se o demonstrar a prova oral produzida na instrução da causa.” (TACrimSP - Ap. nº 913.181/4 - Birigui - 16ª Câ. - Rel. Juiz Eduardo Pereira - J. 23.02.95 - v.u.). “Em sede de roubo, o desaparecimento do revólver não arreda a qualificadora do emprego de arma, se não desponta dúvida razoável de que um dos co-agentes o empregou” (TACRIM-SP-AC-Rel. Sérgio Pitombo - RJD 19/159).

Ainda no mesmo sentido:

“A segura imputação de vítima de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se também a comprovar a circunstância do inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal, sem embargo de falta de apreensão de arma” (JTJ 179/276).

“Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado provado o seu poder vulnerante” (RT 741/610-1).

Já decidiu nesta Corte:

“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma de fogo - Ausência de apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Qualificadora evidenciada pela comprovação da utilização de arma para a perpetração do delito, em face da prova oral colhida e não impugnada (TJSP)” (RT 878/600).

“ROUBO QUALIFICADO - Emprego de arma - Não apreensão do artefato utilizado pelo agente - Irrelevância - Prova suprida pelo depoimento da vítima - Qualificadora que leva em conta a intimidação sofrida pela vítima e não o poderio do armamento utilizado (TJSP)” (RT 872/636)

“ROUBO QUALIFICADO. Concurso de agentes. Emprego de arma. Sentença condenatória. Insurgência. Afastamento da qualificadora do emprego de arma. Inadmissibilidade. Hipótese em que a não apreensão da arma empregada pelo agente na prática do roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial. Recurso não provido” (Apelação Criminal n. 993.08.019984-1 São Paulo 5ª Câmara de Direito Criminal Relator: Marcos Zanuzzi 26.06.08 V.U. Voto nº 16.272).

Entretanto, no presente caso, o armamento foi apreendido e periciado, conforme laudo de fls. 99/104, sendo constatada a eficácia do armamento para a realização de disparos. Do laudo pericial é possível verificar-se, também, que o armamento possuía sinais de oxidação e corrosão, aparentando ser antigo, na forma como descrito pela vítima em suas declarações judiciais.

O delito tipificado no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 também restou bem demonstrado pela prova amealhada aos autos.

A vítima narrou de forma inequívoca que o roubo foi praticado pelo réu, juntamente com outro indivíduo que ela pode reconhecer em solo policial, conforme auto de reconhecimento de fls. 19, tratando-se de um adolescente.

Consoante entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula nº 500, o crime de corrupção de menor trata-se de crime formal, que independe de prova da efetiva corrupção do menor.

Como bem destacado no Voto do Min. Marco Aurélio Bellizze, Relator do Recurso Especial nº 1.127.954-DF, julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, “basta para sua configuração que o agente pratique ou induza o menor a praticar uma infração penal, sendo desnecessária a comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido. Em outras palavras, ainda que o adolescente possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora em análise, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal. Não se pode olvidar que a cada nova prática criminosas em que o menor participe contribui para

aumentar a degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor de ato infracional." Mostra-se, portanto, suficiente a comprovação de que o menor participou de prática delituosa juntamente com o autor do delito, pois o bem jurídico tutelado visa impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção do menor na prática criminosa ou que nela o mantenha, protegendo-se a formação moral e desenvolvimento do menor.

Também neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Autoria e materialidade bem comprovadas. Palavras coerentes e uniformes das testemunhas. Crime do art. 244-B do ECA. Delito formal, a independer de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que participe da ação criminosa. Exegese da Súmula 500 do STJ. Penas, regime e substituição da corporal por restritiva de direitos mantidos. Recurso desprovido" (Apelação nº 3000802-05.2013.8.26.0482, rel. Des. Ivan Sartori, Comarca de Presidente Prudente, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/09/2014)

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

(...) 3. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, 'c', da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. 4. Habeas corpus denegado" (habeas corpus 169.072/SP, 6ª Turma, relator o ministro Og Fernandes, julgamento em 10 de junho de 2010). "Corrupção de menor - Crime formal - Desnecessária a comprovação de que a conduta efetivamente desvirtuou a criança ou o adolescente - Entendimento Não é necessária a demonstração de que a conduta do agente teria efetivamente desvirtuado criança ou adolescente para que o tipo penal do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente reste configurado. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Enunciado n. 500, de sua Súmula de Jurisprudência, de que a corrupção de menores consiste em crime de natureza formal. Para sua caracterização basta, assim, haver a comprovação de que um menor teria participado da prática de um crime juntamente com um agente maior de 18 anos. É, ainda, irrelevante o fato de a criança ou o adolescente ostentar ou não prática anterior de fatos delituosos, uma vez que, a cada novo crime cometido, esse menor se corromperia ainda mais. Pondere-se, por fim, que o bem jurídico protegido por aludido tipo penal tem como objetivo não apenas impedir a inserção desse menor na carreira criminal, mas também que nela permaneça. Pena - Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP - Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (TJSP - Ap. Nº 0030299-19.2014.8.26.0050 - 8ª Câmara - Rel. Grassi Neto - J. 16.04.2015 - grifei)

Saliente-se que não há se falar em bis in idem quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas no crime de roubo e a condenação pelo crime de corrupção de menores. Os delitos são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos.

Forçoso, de outro lado, diante da constatação de que o crime de corrupção de menores se deu em razão da prática do delito de roubo majorado, ou seja, de que por meio de uma única ação, o acusado praticou dois delitos, reconhecer-se o concurso formal entre o delito de roubo majorado e o delito de corrupção de menores ocorrido no mesmo momento.

Também o crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida restou bem caracterizado e demonstrado, diante da prova produzida nos autos.

A testemunha policial narrou ter realizado a abordagem do acusado que estava em uma motocicleta de origem ilícita, conduzida por um adolescente, apreendendo com aquele uma arma de fogo.

O próprio acusado admitiu estar portando o armamento, embora alegando que o havia encontrado dias antes e que o venderia naquela data.

Assim, malgrado a confissão não seja prova dotada de caráter absoluto, no presente caso, ela está em conformidade com os demais elementos coligidos aos autos, tendo sido confirmada pelo depoimento da testemunha em Juízo.

Saliente-se, outrossim, que nenhum documento de porte ou registro da arma de fogo apreendida, que, frise-se, tinha sua numeração suprimida, foi apresentado pelo réu. Ainda, a potencialidade lesiva da arma foi demonstrada pelo laudo pericial de fls. 99/104, que atestou que o revólver apreendido com o acusado era apto à realização de disparos.

Por fim, ao revés do que suscitou a Defesa, não é caso de aplicação do princípio da consunção.

Veja-se que foi imputado ao réu o crime de porte ilegal de arma de fogo em razão de ter sido ele detido portando o armamento, em uma abordagem policial de rotina.

Esta abordagem, conforme se infere do caderno policial, ocorreu no dia 28 de junho do corrente ano, três dias após o roubo praticado por ele em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma, crime este cometido no dia 25 daquele mesmo mês.

Assim, ainda que o armamento tenha sido reconhecido pela vítima como aquele usado pelo réu para a subtração de sua motocicleta, as condutas do réu ocorreram em contextos fáticos absolutamente diversos, violando bens jurídicos distintos e, portanto, caracterizam delitos autônomos.

Assim, diante da prova produzida, conclui-se a subsunção dos fatos narrados ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, estes em concurso formal, e ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material com os demais crimes, sendo parcialmente procedente, portanto, a ação penal.

Passo à dosagem das penas do réu, atentando-me para o critério previsto no artigo 68 do Código Penal.

1. Quanto ao crime de roubo:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que não há razão para impor aumento sobre a pena-base, a qual resta fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, estabeleço o valor de cada dia-multa no mínimo legal, devendo ser corrigido desde a data dos fatos.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública. Em que pese a vigência somente até 31 de dezembro de 2020 do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, em âmbito federal, verifica-se que o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo, decorrente da pandemia do COVID-19, foi reconhecido por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que ainda se encontra em vigência diante de sucessivas prorrogações. Portanto, em âmbito estadual, mantiveram-se vigentes as normas referentes ao reconhecimento do estado de calamidade pública. A agravante tem caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência. De qualquer forma essa circunstância não pode ser ignorada, pois o isolamento social e a quarentena, em razão da pandemia, facilitam a prática do crime. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo

61, inciso II, alínea "j", do Código Penal em 1/6, ficando a pena fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na última fase do cálculo da pena, verifico que o roubo foi praticado com a majorante do concurso de duas ou mais pessoas, devendo ser a pena acrescida de 1/3. Dessa forma, efetuando-se o acréscimo mencionado, fica a pena fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Ainda, o crime foi praticado com a majorante descrita no §2º-A, inciso I, do artigo 157, em razão de ter sido a ameaça exercida com o emprego de arma de fogo. A pena deve ser acrescida de 2/3, ficando fixada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor já estabelecido.

Ressalte-se que inexiste ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade, ofensibilidade e razoabilidade decorrente do reconhecimento das duas majorantes do crime de roubo, uma vez que a conduta descrita no artigo 157, § 2º-A, do Código Penal é extremamente grave, o que levou o Legislador a decidir incrementar a pena diante da necessidade de enérgica repressão e repressão. Sendo assim, para garantia do princípio da separação dos poderes, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas escolhas feitas pelo Poder Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, em determinadas circunstâncias.

Nesse sentido, em caso análogo, já se decidiu:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 273, § 1º-B, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA PARA APENAR DETERMINADOS DELITOS COM MAIOR SEVERIDADE. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA INTERFERIR NAS ESCOLHAS FEITAS PELO PODER LEGISLATIVO. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 2. O Poder Judiciário não detém competência para interferir nas opções feitas pelo Poder Legislativo a respeito da apenação mais severa daqueles que praticam determinados crimes, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: "PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 273, § 1º e § 1º-B, INCISOS V e VI DO CÓDIGO PENAL. TRANSNACIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECONHECIDO CONCURSO FORMAL." 4. Agravo regimental DESPROVIDO." (RE 829226 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 05-03-2015 PUBLIC 06-03-2015) Outrossim, o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal não traz a exigência de aplicação pelo Magistrado de uma única causa de aumento de pena quando houver concurso de majorantes. Trata-se de uma faculdade, que deve ser justificada, como o foi neste caso concreto.

Neste sentido:

"Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, "D" E "I". ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, "A") E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE "FOTOGRAFAR" MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A conduta consubstanciada em "fotografar" cenas com pornografia

envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), com redação dada pela Lei nº 10.764/2003, notadamente à expressão “produzir fotografia”, cujo valor semântico denota o comportamento de “dar origem ao registro fotográfico de alguma cena”. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 241 do ECA, em razão de ter fotografado sua enteada de seis anos de idade em cenas de sexo explícito. Tipicidade da conduta devidamente caracterizada e apenada. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Boletim Criminal Comentado-março 2019 (semana 2) 8 Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.” (HC 110960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23-09-2014 PUBLIC 24-09-2014)

Veja-se, ainda, especificamente acerca das causas de aumento de pena do crime de roubo após a vigência da Lei nº 13.654/18: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobressaindo as outras, não sendo admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento.

3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)

“Apelação – Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (fatos que ocorreram após o advento da Lei nº 13.654/18) - Materialidade e autoria demonstradas - Confissão dos réus, que foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos - Depoimentos das vítimas e dos policiais militares que atenderam a ocorrência suficientes para justificar o édito condenatório - Crime impossível não caracterizado - Pretensão à desclassificação para forma tentada do delito - Descabimento - Entendimento da Súmula 582, do C. STJ - Condenação mantida - Dosimetria - Penas-base fixadas no mínimo legal - Agravante da reincidência compensada com atenuante da confissão - Exasperação das penas em 1/3 pelo concurso de pessoas e elevada, novamente, em 2/3, pelo emprego de arma de fogo - Impossibilidade de reconhecimento de crime único - Concurso formal bem aplicado -

Regime inicial fechado mantido – Recursos improvidos.”

(TJSP; Apelação Criminal 1502842-89.2018.8.26.0019; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 09/10/2019).

À míngua de outras causas modificadoras, torno essa pena definitiva.

2. Quanto ao crime de corrupção de menores:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que não há razão para impor aumento sobre a pena-base, a qual resta fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, nos termos da fundamentação já citada. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal em 1/6, ficando a pena fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno definitiva a pena.

Considerando-se que há concurso formal entre o delito de roubo majorado e o delito de corrupção de menores relativo à prática desse roubo, aplica-se a regra contida no artigo 70 do Código Penal. Contudo, no presente caso, deve-se observar o disposto no parágrafo único do referido artigo, uma vez que o acréscimo da fração excederia a pena cabível pela regra contida no artigo 69 do Código Penal. Portanto, deverão ser as penas somadas, sendo fixadas em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

3. Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo:

Atendendo às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que não há razão para impor aumento sobre a pena-base, a qual resta fixada em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Considerando a situação econômica do réu, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, verifico que o delito foi cometido em ocasião de calamidade pública, nos termos da fundamentação já citada. Impõe-se, portanto, o aumento de pena pelo reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

De outro lado, é caso de reconhecimento da confissão espontânea do acusado quanto a este delito e, portanto, fica esta circunstância compensada com a circunstância agravante relativa à calamidade pública.

Na terceira fase da dosimetria, verifico que não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno definitiva a pena.

As penas dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores devem ser somadas às penas do crime de porte ilegal de arma de fogo, de acordo com as regras do concurso material de delitos, resultando na pena final de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor já estabelecido.

Considerando as peculiaridades do presente caso, observando-se a gravidade inerente aos delitos e as repercussões deste no meio social, tendo em vista que se trata de roubo praticado em concurso de agentes, com a participação de adolescente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma, bem como de porte ilegal de arma de fogo cometido em momento posterior ao roubo, além da somatória total de penas, fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena (LEP, art. 111).

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra espécie de pena, diante do montante de pena imposta, bem como por ter sido o crime praticado com grave ameaça à pessoa. Pelos mesmos motivos, incabível o sursis.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito dos seus comportamentos no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua

especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação - Tráfico de entorpecentes - Materialidade e autoria bem demonstradas - Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa - Ré confessa, ademais - Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos - Precedentes - Pena de multa que se corrige - Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante - Regime fechado justificado - Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito - Detração - Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais - Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei) Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o réu HELIO HERNANI DOS SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente no País na época do fato, devidamente corrigidos, na forma da Lei, até o efetivo pagamento, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, estes em concurso formal, na forma do artigo 70 do Código Penal, e ao disposto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso material com os demais crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar desta em liberdade, estando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se a gravidade do crime de roubo, praticado com grave ameaça contra a vítima, exercida com o emprego de arma de fogo, em concurso com adolescente, bem como do delito de porte ilegal de arma de fogo cometido em data posterior àquele roubo.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito, mormente no momento em que foi proclamado culpado em primeiro grau de jurisdição.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Ausente demonstração mínima dos prejuízos integrais sofridos pelas vítimas, e não tendo havido pedido nesse sentido, deixo de condenar o réu nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo do direito de reparação dos ofendidos a ser perseguido na esfera cível.

Custas na forma da Lei.

P. R. I. C.

São Vicente, 26 de setembro de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA